



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo

Tribunal Pleno – **SEÇÃO ESTADUAL**

Sessão: **14/8/2024**

Exame Prévio de Edital – Referendo e Julgamento

E-001: TC-012950.989.24-4.
Interessada: Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.
Representante: M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda.
Responsável: Solange Pereira do Nascimento, supervisora de licitações.
Assunto: Representação contra edital de pregão eletrônico 57/00009/23/05 para a contratação de empresa especializada para ampliação e substituição do parque existente de switches, incluindo os serviços de instalação, configuração, suporte técnico e garantia, pelo período de 36 meses, para atender as novas demandas tecnológicas oriundas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do Centro Paula Souza e das Prefeituras.
Advogado: Fernanda Mary de Oliveira Loureiro (OAB-SP 114.347), Rafael Vêras (OAB-RJ 147.169), Leonardo Coelho (OAB-RJ 155.210), Pedro Schelbauer (OAB-PR 81.579), Marcos Jordão Amaral Filho (OAB-SP 74.481).

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. EXAME PRÉVIO DE EDITAL. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL.

Relatório

Trata-se de representação de **M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda.**, em face do edital de pregão eletrônico 57/00009/23/05, lançado pela **Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE**, para a contratação de empresa especializada para ampliação e substituição do parque existente de switches, incluindo os serviços de instalação, configuração, suporte técnico e garantia, pelo período de 36 meses, para atender as novas demandas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

tecnológicas oriundas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do Centro Paula Souza e das Prefeituras.

Em síntese, a **representante** afirma que, nos autos do Mandado de Segurança autuado sob o n. 1063507-50.2023.8.26.0053, foi proferida sentença judicial reconhecendo a irregularidade dos seguintes pontos do edital: **(a)** a exigência de que o fabricante dos equipamentos a serem fornecidos esteja listado no relatório do GARTNER de 2022, **(b)** a exigência de que a fabricante dos equipamentos deverá possuir escritório de representação e suporte técnico no Brasil; e **(c)** a vedação à apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em comum. A sentença, publicada em 08/01/2024, determinou a invalidação dos correspondentes itens do edital, e foi objeto de recurso de apelação pela FDE. No momento do protocolo da inicial, o recurso encontrava-se pendente de julgamento, com parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento, mantendo-se a sentença.

A exordial esclarece, quanto à exigência de que o fabricante esteja listado no relatório GARTNER, que referida instituição é uma entidade privada, constituída nos Estados Unidos, e cujo sítio oficial informa, na seção de perguntas e respostas, que o fato de um fabricante não estar listado no relatório “não significa que o fornecedor não seja viável ou competitivo. Pode indicar que a estratégia ou as funções do fornecedor diferem dos critérios de inclusão ou aborda um mercado-alvo diferente”. A petição afirma, ainda, que a inclusão de empresas no citado relatório é uma discricionariedade da entidade privada.

Determinou-se a **sustação cautelar** da licitação, em despacho proferido em 10/06/2024, por se vislumbrar “aparente irregularidade na exigência de habilitação, consistente na demonstração de que o fabricante ou fornecedor do objeto que se pretende contratar encontra-se referenciado em lista divulgada e organizada por entidade privada internacional. Sobretudo, porque a própria



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

entidade privada reconhece em seu sítio oficial que a ausência de determinado agente da lista não significa que esteja materialmente impedido de realizar a contento as atividades dele esperadas” (ev. 15).

Em seus esclarecimentos, a **FDE** defendeu a regularidade dos atos praticado (protocolo em 14/06/2024, ev. 30).

A **Assessoria Técnica** se manifestou pela **procedência integral** da representação (pareceres juntados em 15/07/2024, ev. 48), pois:

(a) Embora detentora de reputação e credibilidade reconhecidos internacionalmente, a consultoria privada GARTNER elabora relatórios que “não abarcam necessariamente todas as tecnologias e muito menos todos os fornecedores e soluções existentes no mundo, já que isso seria inviável”. Além disso, os esclarecimentos prestados pela FDE revelam que “relatório da GARTNER está sendo usado como um processo de pré-qualificação dos fabricantes dos bens almejados pela Representada, já que ele limita a disputa a doze fabricantes previamente selecionados. Tal procedimento, contudo, afronta o regramento disposto no artigo 80, da Lei nº 14.133/2021, já que a pré-qualificação não foi realizada pelo Órgão licitante, mediante edital público e aberto permanentemente, mas por uma consultoria estrangeira, segundo seus próprios critérios de seleção e aprovação”. Por esses motivos, em suma, opinou pela procedência da crítica formulada.

(b) Não encontra amparo legal a exigência para que a fabricante dos equipamentos prestasse suporte técnico no Brasil (item 8.1.1.4.4 do edital e item 13.2 do termo de referência). Alternativamente, a manutenção das condições de suporte técnico em território nacional pode ser, eventualmente, oferecida por distribuidor autorizado no país. Sobretudo por se voltar à etapa de habilitação, a previsão editalícia, na forma em que se encontra, ultrapassa o disposto no artigo 67 da Lei 14.133/2021. Por esse motivo, a crítica é procedente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

(c) Igualmente, não encontra amparo legal a vedação à apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em comum (item 8.1.1.4.3 do edital). A legislação não contempla essa vedação que, por isso, tem sido condenada por este e. TCE-SP (cf. TC-11767/989/19, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Renato Martins Costa, sessão de 26/06/2019).

A representação foi distribuída por conexão com o TC-18880/989/23-1, que albergou representação formulada pela mesma representante, em face de versão anterior do edital. Naquela oportunidade, determinou-se o arquivamento do feito, por intempestividade, sem apreciação do pleito cautelar ou do mérito.

O **Ministério Público de Contas** acompanhou integralmente a Assessoria Técnica e se manifestou pela **procedência integral** da representação (parecer juntado em 15/07/2024, ev. 48).

Vistas regimentais à **Procuradoria da Fazenda do Estado**, que optou por não se pronunciar (ev. 63).

É o relatório.

gjj



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

VOTO

TC-12950/989/24-4

Preliminar

Em preliminar, apresento para referendo do Tribunal Pleno decisão monocrática mediante a qual se determinou a sustação cautelar do certame cujo edital ora se aprecia.¹

Mérito

Em nome dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração dos processos, encurto razões para acolher *integralmente* os pareceres da Assessoria Técnica, constantes do ev. 48 destes autos, nos termos do relatório, adotando-os como fundamentação do presente voto, com arrimo no art. 8º, Parágrafo único da Lei Estadual de Processo Administrativo.

Nesses termos, voto pela **procedência integral** da representação, determinando-se à Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, caso decida prosseguir com o certame, que retifique o edital, nos termos a seguir resumidos:

(a) Eliminar a exigência de que o fabricante dos equipamentos esteja listado em relatório GARTNER (Anexo I – Termo de Referência – Item 9 – Requisitos Gerais).

(b) Eliminar a exigência para que a fabricante dos equipamentos preste suporte técnico no Brasil (item 8.1.1.4.4 do edital e item 13.2 do termo de referência).

¹ Cópia do despacho de sustação cautelar encontra-se anexo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

(c) Eliminar a vedação à apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em comum (item 8.1.1.4.3 do edital e item 13.2 do termo de referência).

(d) Revisar a integralidade do ato convocatório e seus anexos, após a adoção das providências acima, para o fim de identificar e corrigir eventuais contradições internas provenientes das correções ora determinadas, **republicando** o correspondente aviso de edital, observando-se a integralidade dos prazos legais aplicáveis.

É como voto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

ANEXO – DESPACHO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR

Exame Prévio de Edital – Sustação cautelar

Processos: TC-12950/989/24-4.

Interessada: Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

Representante: M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda.

Responsável: Solange Pereira do Nascimento, supervisora de licitações.

Assunto: Representação contra edital de pregão eletrônico 57/00009/23/05 para a contratação de empresa especializada para ampliação e substituição do parque existente de switches, incluindo os serviços de instalação, configuração, suporte técnico e garantia, pelo período de 36 meses, para atender as novas demandas tecnológicas oriundas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do Centro Paula Souza e das Prefeituras.

Advogado: Fernanda Mary de Oliveira Loureiro (OAB-SP 114.347), Rafael Vêras (OAB-RJ 147.169), Leonardo Coelho (OAB-RJ 155.210) e Pedro Schelbauer (OAB-PR 81.579).

Trata-se de representação de **M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda.**, em face do edital de pregão eletrônico 57/00009/23/05, lançado pela **Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE**, para a contratação de empresa especializada para ampliação e substituição do parque existente de switches, incluindo os serviços de instalação, configuração, suporte técnico e garantia, pelo período de 36 meses, para atender as novas demandas tecnológicas oriundas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do Centro Paula Souza e das Prefeituras.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Em síntese, a **representante** afirma que, nos autos do Mandado de Segurança autuado sob o n. 1063507-50.2023.8.26.0053, foi proferida sentença judicial reconhecendo a irregularidade dos seguintes pontos do edital: **(a)** a exigência de que o fabricante dos equipamentos a serem fornecidos esteja listado no relatório do GARTNER de 2022, **(b)** a exigência de que a fabricante dos equipamentos deverá possuir escritório de representação e suporte técnico no Brasil; e **(c)** a vedação à apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios em comum. A sentença determinou a invalidação dos correspondentes itens do edital, e foi objeto de recurso de apelação pela FDE. O recurso encontra-se pendente de julgamento, com parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento, mantendo-se a sentença.

Em que pese o recurso de apelação, a FDE determinou administrativamente a invalidação dos correspondentes itens do ato convocatório, em relação ao lote reservado a micro e pequenas empresas, e deu sequência ao certame, adjudicando o objeto naquele lote reservado. Todavia, em relação ao lote principal, a FDE se limitou a republicar o edital, mantendo-se as exigências reconhecidas como irregulares pela sentença judicial acima referida. Contra este ato é que se insurge a ora representante.

A exordial esclarece, quanto à exigência de que o fabricante esteja listado no relatório do Gartner, que referida instituição é uma entidade privada, constituída nos Estados Unidos, e cujo sítio oficial informa, na seção de perguntas e respostas, que o fato de um fabricante não estar listado no relatório “não significa que o fornecedor não seja viável ou competitivo. Pode indicar que a estratégia ou as funções do fornecedor diferem dos critérios de inclusão ou aborda um mercado-alvo diferente”. A petição esclarece, ainda, que a inclusão de empresas no citado relatório é uma discricionariedade da entidade privada.

Por esses motivos, requer a **sustação cautelar** da licitação.

A representação foi distribuída por conexão com o TC-18880/989/23-1, que albergou representação formulada pela mesma representante, em face de versão anterior do edital. Naquela oportunidade, determinou-se o arquivamento feito, por intempestividade, sem apreciação do pleito cautelar ou do mérito.

É o relatório. Decido.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Para fins de registro, deve-se anotar que: **(a)** o edital informa o dia 29/05/2024 como sendo a data de sua assinatura; **(b)** a representante protocolou sua exordial neste TCE-SP no dia 06/06/2024, quinta-feira, às 17h03min., após o horário de expediente; **(c)** a data designada para a sessão de pregão é 12/06/2024, quarta-feira; e **(d)** há notícia de questionamento judicial, nos termos no relatório.

Registra-se que o presente feito não examina o cumprimento da sentença judicial mencionada no relatório e não contém qualquer juízo a respeito do correspondente processo judicial.

Evidencia-se, contudo, que há aparente irregularidade na exigência de habilitação, consistente na demonstração de que o fabricante ou fornecedor do objeto que se pretende contratar encontra-se referenciado em lista divulgada e organizada por entidade privada internacional. Sobretudo, porque a própria entidade privada reconhece em seu sítio oficial que a ausência de determinado agente da lista não significa que esteja materialmente impedido de realizar a contento as atividades dele esperadas. Logo, não se é razoável, a partir desse único elemento, alijar eventual agente privado de participação de licitação pública.

Além disso, observa-se que a própria FDE determinou a invalidação de idênticas exigências àquelas ora questionadas, porém, apenas em relação ao lote reservado para micro e pequenas empresas. Neste particular aspecto, não se identifica qual teria sido a razão jurídica para justificar a distinção entre o tratamento conferido pela FDE ao lote exclusivo para micro e pequenas e o lote principal.

Diante desse quadro, com fundamento no art. 53, parágrafo único, nº 10, do RITCESP, DETERMINO a **SUSPENSÃO** do processo licitatório, o qual deverá ser assim mantido até que este Tribunal Pleno profira decisão final sobre o caso, abstendo-se a Administração e seus agentes da prática de quaisquer atos pertinentes à licitação em epígrafe, **excetuando-se** a prerrogativa de revogar ou anular o edital impugnado, a ser exercida no prazo acima fixado, caso em que deverá **comunicar imediatamente** este e. Tribunal, trazendo aos autos o respectivo ato devidamente publicado, sob pena de multa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

NOTIFICO a Administração para que comprove o cumprimento da ordem de suspensão, prestando todas as informações necessárias à elucidação das críticas formuladas, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, quando deverá certificar a veracidade do edital já acostado aos autos ou, alternativamente, juntar cópia do edital impugnado, tudo para o fiel cumprimento do previsto no art. 171, §§ 1º e 2º da Lei 14.133/2021.

Alerto a Administração de que os documentos juntados nestes autos deverão estar no formato “.pdf”, com recurso de pesquisa por expressões aberto e disponível, sob pena de ser determinado o seu desentranhamento.

Igualmente, a Administração deverá ser alertada para o disposto nos artigos 25, § 3º, 54, *caput*, e § 2º da Lei 14.133/2021, que determinam a divulgação, em sítio eletrônico oficial, do edital e de todos os seus anexos, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

O descumprimento da ordem de suspensão e das demais providências acima determinadas ensejará a aplicação de sanção pessoal ao agente subscritor do ato ora impugnado, **Solange Pereira do Nascimento, supervisora de licitações**, nos termos do art. 104, III da Lei Complementar 709/1993.

Publique-se.

Ao Cartório para as devidas providências.

GC, 10 de junho de 2024.

ROBSON MARINHO

CONSELHEIRO

gjj